

1507087-59.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... do delito de associação para o tráfico, previsto no supracitado artigo da lei de drogas, é necessário que haja prova de estabilidade e da organização entre os agentes para a finalidade de cometerem tráfico de drogas, o que não restou demonstrado nos autos. A propósito: Direito Penal. Associação para o tráfico de drogas/ entorpecentes. Ausência de animus associativo. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507087-59.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507087-59.2022.8.26.0228 PD 432/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON CARLOS MELO MESSIAS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos, 26 de abril de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Caio Bueno Bandeira Lins de Moraes, presente o réu Anderson Carlos Melo Messias, acompanhado pelo Dr. Sérgio André Weise Chinéz - Defensor Público. Presente o réu Caio Cesar Pompeu Pereira, acompanhado pelo Dr. Edson Bernardo da Silva - OAB/SP 394.293.. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa do réu Anderson Carlos Melo Messias foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pela Defesa do réu Caio Cesar Pompeu

Pereira foi dito que desistia da oitiva das testemunhas Adrielle Ribeiro Novais e Taiz Amanda Pompeu Pereira, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório dos réus nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: Alegações finais orais colhidas por meio de áudio e vídeo, gravadas em mídia própria juntada aos autos. Em síntese, requereu a condenação de ambos os acusados, pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas, assim como a absolvição no concernente ao crime de associação para o tráfico. Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu Anderson, assim se manifestou: "MM. Juiz, ANDERSON CARLOS MELO MESSIAS responde a este processo como incurso nos artigos 33, caput, 35, caput, ambos da Lei de 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. Regularmente processado, em instrução probatória foram ouvidos apenas e tão somente policiais envolvidos na ocorrência, com derradeiro interrogatório do réu e do corréu. Os policiais aduziram que viram o réu e o corréu em movimentação típica de tráfico e, realizada a abordagem, encontraram dinheiro com o corréu e drogas com o réu. O réu e o corréu confessaram a prática do tráfico e aduziram ser a primeira vez que traficavam. Pois bem. Fora os parcos depoimentos dos policiais, não há provas que indiquem a traficância. Ao que consta, sem maiores explicações, os réus foram abordados aleatoriamente e sozinhos, em circunstâncias pouco esclarecidas. Isso torna insegura a prova dos autos. Sem dúvida, as contradições ocorreram em pontos nevrálgicos que induziam a autoria da traficância ao ora defendido, de modo que fragiliza sobremaneira a prova acusatória, até porque: "Se em relação a qualquer pessoa que contingentemente testemunha um fato, é explicável haver, entre seus relatos, algumas discrepâncias quanto às circunstâncias que dão moldura ao acontecimento, é, no entanto, inadmissível, porquanto inexplicável, a mesma discrepância quando se trata de policial, especialmente se ela se refere àquilo que foi determinante da atuação, deste e serve à constatação objetiva do fato" (JUTACRIM-46/365) Ante todo o exposto, requer-se seja a presente ação julgada improcedente para ABSOLVER os acusados com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela insuficiência probatória. Do mesmo modo, o réu deve ser ABSOLVIDO do crime de associação para o tráfico, uma vez que as provas nesse ponto se resumem ao fato de o réu ter sido preso após investigações por meio de interceptação telefônica. Inegavelmente, porém, as testemunhas de acusação não formaram um conjunto probatório substancial e seguro para sustentar uma condenação. Isto porque os policiais admitiram que o réu não foi mencionado durante as investigações. Ora, para que haja enquadramento do delito de associação para o tráfico, previsto no supracitado artigo da lei de drogas, é necessário que haja prova de estabilidade e da organização entre os agentes para a finalidade de cometerem tráfico de drogas, o que não restou demonstrado nos autos. A propósito: Direito Penal. Associação para o tráfico de drogas/ entorpecentes. Ausência de animus associativo. "A existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de atos delituosos não configura sociedades criminais e delito previsto no art. 435 da Lei nº 11.343/06. Mostrando-se desproporcional a pena aplicada, é imperativa a sua readequação, fixando-a de modo que cumpra a sua função social, de caráter preventivo e repressivo, observado as circunstâncias do art. 59 do Código Penal e § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06. A eventual situação de miserabilidade dos apelantes não implica em isenção da pena de dias multa, por ser essa, uma sanção penal e medida necessária e eficaz ao duplo caráter da pena, quais sejam, preventivo e repressivo" (TJMT- 1ª Câmara Criminal- AP 71941/09- rel. Juvenal Pereira da Silva- j. 19.01.2010- DJE 28.01.10); Direito Penal. Tráfico de Drogas. Quadrilha ou bando. Vínculo associativo não comprovado. "Inexistindo provas judicializadas da convergência de vontades, estável ou permanente, não há que se falar em delito de formação de quadrilha, pois a sua caracterização exige prova inconteste de vínculo associativo permanente com a finalidade de cometer crimes, formando uma verdadeira sociedade sceleris para essa finalidade" (TJMG- 3ª C. - AP 1.0143.05.009070-1/001- rel. Antonio Armando dos Anjos- j. 15.12.2009- DOE

10.03.2010). Entorpecente - Associação para o tráfico - Caracterização - Concurso de duas ou mais pessoas, com o animus associativo, organização em bando, com caráter de habitualidade para o fim único da prática reiterada, ou não, do comércio ilícito de drogas (TJMG, RT 833/609) Tóxicos - Associação criminosa - artigo 14 da Lei nº 6.368/76 - ausência de comprovação de associação estável e duradoura entre o réu e os demais acusados - Condenação - Impossibilidade - Reconhecimento da associação eventual dos agentes, aplicando-se a causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 18 daquele diploma legal - Hipótese - recurso parcialmente provido (Apelação criminal 494.062.3/2, Americana, 5ª Câmara Criminal, Rel. Tristão Ribeiro, 13-3-2006, v.u., Voto nº 7.325) Nesse sentido também: "O art. 35 traz modalidade especial de quadrilha ou bando (art. 288 do CP). Contudo, diferentemente da quadrilha, a associação para o tráfico exige apenas duas pessoas (e não quatro), agrupadas de forma estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 34 (tráfico de maquinário) desta Lei" (pág. 204 e ss.). Mesmo que se considerem os depoimentos policiais como provas robustas para reconhecer o crime de tráfico, ainda assim não ficou, por seu turno, comprovada a estabilidade exigida pela figura típica. Presumir-se a associação constituiria intolerável inversão do ônus da prova: a acusação não demonstrou, seja por depoimentos de terceiros ou por outros meios cabíveis, que os acusados traficavam juntos de modo estável e permanente. Não há o menor indício de que o acusado dedica-se, com frequência ou não, à prática de tráfico de drogas. Não há qualquer prova, ainda que tênue, que justifique a grave imputação feita pelo Ministério Público, motivo pelo qual deve o acusado ser absolvido do delito supracitado. Tem-se ainda que jurisprudência entende que o delito do artigo 35 é subsidiário em relação aos demais crimes previstos na mesma lei, sendo cabível a condenação somente quando não demonstrada a prática dos delitos principais: "O crime definido na Lei de Tóxicos, em seu art. 14 (atual art. 35), diz respeito à associação de agentes que não chegam a praticar qualquer dos outros delitos previstos em norma incriminadora. Assim, tal dispositivo é de se considerar como subsidiário em relação aos outros ilícitos mais graves, motivo pelo qual somente cabe sua configuração nos casos de não demonstrada a prática dos denominados delitos principais. Sua funcionalidade, pois, pode ser figurada como a de soldado de reserva da ordem jurídica" (RJTJRS 106/113). Ante todo o exposto, requer-se seja a presente ação julgada totalmente improcedente para ABSOLVER o acusado com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No caso de improvável sentença condenatória do acusado, por eventualidade, requer-se: (i) a fixação da pena no patamar mínimo, considerando a primariedade da ré e a confissão espontânea dos réus; (ii) a aplicação do redutor no máximo para todos os réus, que preenchem os requisitos legais para tanto; e (iii) a concessão de regime mais brando, diverso do fechado, em plena observância ao ditame constitucional da individualização da pena, (iv) com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante o caminhar jurisprudencial, mormente após o julgamento pelo Pleno do C. STF do HC nº 97.256/RS, declarando flagrantemente inconstitucional o malfadado artigo 44 da Lei de Drogas, o que, inclusive, motivou a promulgação da resolução nº 05 do Senado Federal, a qual suspendeu a vedação legal em referência. Nesse ponto, é importante destacar o recente julgado do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido da inconstitucionalidade

da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos). A decisão ocorreu no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1052700, de relatoria do ministro Edson Fachin, que teve repercussão geral reconhecida e mérito julgado pelo Plenário Virtual. Na ocasião foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É INCONSTITUCIONAL A FIXAÇÃO EX LEGE, COM BASE NO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.072/1990, DO REGIME INICIAL FECHADO, DEVENDO O JULGADOR, QUANDO DA CONDENAÇÃO, ATER-SE AOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL". Por fim, (vi) o recurso em liberdade, na ausência de requisitos para a cautelaridade." Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu Caio, assim se manifestou: "MM. Juiz, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado Caio.

Subsidiariamente, por conta da confissão judicial, requer: a exclusiva responsabilização pelo art. 33 da Lei de Drogas, com o redutor do tráfico privilegiado, além da substituição do art. 44 do CP." Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos. CAIO CESAR POMPEU PEREIRA e ANDERSON CARLOS MELO MESSIAS, qualificados nos autos, foram denunciados a fls. 134/135 como incurso no artigo 33, "caput" e artigo 35, "caput", ambos da Lei nº11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque em tese previamente associados para o cometimento de tráfico de drogas, em 24 de março de 2022, por volta das 15h04min, na Rua Piava, altura do nº20, bairro Itaquera, nesta cidade e Comarca da Capital, traziam consigo e vendiam, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 09 (nove) porções de cocaína, substância causadora de dependência física e/ou psíquica. Os réus foram presos em flagrante delito por Policiais Civis e permaneceram custodiados no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 148/150), os réus foram citados, sendo apresentadas respostas à acusação. Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais civis Ricardo e Carolina, responsáveis pela prisão em flagrante. A Defesa do réu Caio dispensou as testemunhas que arrolou. Os réus foram ao final interrogados. Na fase de debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do ambos os acusados, pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas, assim como a absolvição no concernente ao crime de associação para o tráfico. Os Defensores dos réus pleitearam a absolvição. Subsidiariamente, por conta da confissão judicial, requereram: a exclusiva responsabilização pelo art. 33 da Lei de Drogas, com o redutor do tráfico privilegiado, além da substituição do art. 44 do CP. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A presente ação penal deve ser julgada procedente em parte. Com efeito, na medida em que os acusados não registram outras passagens em conjunto na prática de tráfico de drogas, inexistindo ainda elementos cabais quanto a habitualidade e reiteração nessa prática criminosa, deve ser afastada desde logo a imputação do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Prevalece, no entanto, a imputação do delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pelo qual ambos os réus devem ser condenados. Co-autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo B.O. de fls. 02/05; pelo A.E.A. de fls. 06; pelo Laudo de Constatação de fls. 08/10; pelo L.E.Q.T. de fls. 155/157; pelos depoimentos prestados pelos Policiais Civis nas duas fases procedimentais; e pela confissão de ambos os réus em Juízo. Extrai-se dos depoimentos dos policiais que na data dos fatos se dirigiram até o local dos fatos para averiguar notícias de tráfico de drogas do "Disque Denúncia" (nºW2203102345 - fls. 47/49 e nº W2203102331 - fls. 47/51), acerca de indivíduos que estariam no local comercializando drogas. Ao chegarem no local, por meio de campana velada, avistaram Caio e Anderson em movimentação típica da traficância, ou seja: CAIO recepcionava os usuários compradores, solicitando que suspendessem as camisas que trajavam e deles recebia dinheiro; na sequência os usuários compradores eram encaminhados até ANDERSON que fazia a entrega das drogas. Após isso se repetir cerca de quatro vezes, os policiais procederam à abordagem dos réus. Em busca pessoal foi encontrada em poder de CAIO a quantia de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) em notas trocadas. Já em poder de ANDERSON foi encontrada uma pochete, em cujo interior estavam as drogas acima indicadas. Interrogados em Juízo, nesta data, os réus confirmaram todas as circunstâncias supra, confessando portanto o delito de tráfico. De todo o exposto, conclui-se, quanto ao crime do artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, que há de se acolher o pedido absolutório do "Parquet", para reconhecer que não há provas suficientes de que os acusados estivessem previamente associados, de modo estável, habitual e permanente, para a prática do tráfico ilícito de drogas. Mas quanto ao crime de tráfico, por ter sido cabalmente comprovado, mister se faz a procedência em parte da denúncia, para que os acusados sejam condenados como incurso no artigo 33 da Lei de Drogas. Passo à dosagem das penas. Na fase do artigo 59 do Código Penal, diante da primariedade técnica dos acusados, fixo a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A atenuante da confissão não permite a diminuição além do patamar mínimo já estabelecido. Tratando-se da primeira condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, há possibilidade de tratamento punitivo mais benéfico, com a aplicação do disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo

33, § 4º. Assim, reduzo a pena supra em 2/3 (dois terços), o que perfaz, em definitivo, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação penal para: a) CONDENAR os réus CAIO CESAR POMPEU PEREIRA e ANDERSON CARLOS MELO MESSIAS ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-os como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06; e b) ABSOLVÊ-LOS, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, quanto ao delito do artigo 35, "caput", da Lei nº. 11.343/06. Ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao deferir a ordem, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Por conta disso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade a ser regulamentada no Juízo das Execuções nos termos do artigo 46 do Código Penal. Na hipótese de descumprimento das condições impostas, os sentenciados deverão iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto. Por conta da concessão da pena alternativa, determino a expedição de alvarás de soltura clausulados em favor dos dois sentenciados. O valor em dinheiro arrecadado deverá ser revertido em favor da SENAD. Demais objetos apreendidos devem ser destruídos. A droga deve ser incinerada. Os sentenciados saem desde logo intimados a fazerem cada qual o pagamento da pena de multa, calculada em R\$ 6.706,40, no prazo de quinze dias. Providenciem-se informações complementares quanto aos HCs de fls. 88/99 e 103/114. Certificado o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es) réu Anderson:

Dr.(a).Defensor(es) réu Caio:

Réu Anderson:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA